

1500862-84.2022.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL RAUCH

Comarca: Itapevi

Foro: Foro de Itapevi

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... a aplicação da forma privilegiada do tráfico.

Com efeito, os réus estão sendo condenados pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes e, conjuntamente, pelo delito de associação para o tráfico. É incompatível com essa condenação, portanto, a incidência do privilégio, nos termos do enunciado 23 da edição n.º 131 da Jurisprudência em Teses do C. STJ, que assim ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapevi

Foro de Itapevi

Vara Criminal

Rua Vereador Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405, Itapevi-SP - cep 06660-280

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500862-84.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500862-84.2022.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2124323/2022 - DEL.POL.BARUERI, 24808537 -

DEL.POL.BARUERI, 2124323 - DEL.POL.BARUERI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERICK APARECIDO XAVIER e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL RAUCH

Vistos.

ERICK APARECIDO XAVIER e RICHARD TEOFILO SOUZA, qualificados nos autos da Ação Penal em epígrafe que lhes move a Justiça Pública, foram denunciados como incurso nos arts. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/06, e arts. 14 e 16, ambos da Lei n.º 10.826/03, todos na forma do artigo 69, caput, do CP.

Isso porque, em data incerta, mas até o dia 06 de maio de 2022, os réus associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Ainda, no dia 06 de maio de 2022, por volta das 07h00min, na Rua da Paz, n.º 43, Jardim Paulista, nesta cidade e Comarca de Itapevi, os réus, previamente ajustados e com unidade de desígnios, preparavam, tinham em depósito e guardavam drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Outrossim, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, os réus, previamente ajustados e com unidade de desígnios, possuíam e mantinham sob sua guarda, 09 (nove) cartuchos deflagrados de calibre 22, 02 (dois) cartuchos deflagrados de calibre 38, 03 (três) munições íntegras de calibre 22, 08 (oito) munições íntegras de calibre 380 e 08 (oito) munições íntegras de calibre 9, sem

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os réus foram notificados (f. 164 e 167) e apresentaram defesa prévia (f. 155 e 186-195).

Não sendo caso de rejeição da denúncia ou de absolvição sumária, a exordial acusatória foi recebida por decisão datada de 16 de setembro de 2022 (f. 196-197).

Os réus foram citados, dando-se seguimento à persecução penal em Juízo.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas, tendo-se interrogado os réus ao final (f. 295). Na sequência, encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais (f. 293-294).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de ação penal na qual o Ministério Público imputa aos acusados a prática das infrações penais previstas nos arts. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/06, e arts. 14 e 16, ambos da Lei n.º 10.826/03, todos na forma do artigo 69, caput, do CP.

De início, deixo de enfrentar a imputação aos acusados do crime previsto no art. 16 da Lei n.º 10.826/03, eis que não descrito na exordial acusatória.

Conforme se depreende da denúncia, o Ministério Público imputou aos acusados prática do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, mas não descreveu os fatos relativos a esse crime.

De fato, não há qualquer narração de que os réus estivessem em posse de munição de arma de fogo de uso restrito – há, apenas, notícia de que eles foram encontrados em posse de munição de arma de fogo de uso permitido, de acordo com os laudos periciais de f. 231-236, 260-262 e 290-292.

Tem-se, pois, que a capitulação do art. 16 da Lei n.º 10.826/03 cuidou-se de mero erro material, razão pela qual deixo de analisar seu mérito.

Feitas essas considerações e, no mais, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

Na parte conhecida, a pretensão acusatória é parcialmente procedente.

Ressalto, desde já, que, pela descrição contida na denúncia, bem como pelos fatos comprovados em juízo, estou em desclassificar a conduta de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, prevista no art. 14 da Lei n.º 10.826/03, para o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 12 do mesmo diploma legal.

Como bem narrado pelo órgão acusatório, os acusados “possuíam e mantinham sob sua guarda, no interior na residência localizada na Rua da Paz, nº 43, Jardim Paulista, nesta cidade e comarca de Itapevi” (f. 87) munições de arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Os réus não foram flagrados portando as munições ou praticando quaisquer dos núcleos do tipo penal do art. 14 da Lei n.º 10.826/03, mas possuíam e mantinha sob sua guarda as munições “no interior de sua residência”.

A descrição dos fatos melhor se subsume ao art. 12 da Lei n.º 10.826/03, de modo que a desclassificação é imperativa.

Veja-se, no ponto, caso semelhante na jurisprudência:

Apelação – Porte ilegal de munições e arma de fogo de uso permitido – art. 14 da Lei n.º 10.826/03 – Associação Criminosa – art. 288, do Código Penal – Sentença condenatória. Recurso Defensivo pleiteando, preliminarmente, a nulidade da prova colhida, diante da ocorrência de violência policial. No mérito, pleito de absolvição, por falta de provas. Pedidos subsidiários de desclassificação para a conduta do art. 12, da Lei 10.826/03, bem como o afastamento da causa de aumento do art. 288, parágrafo único, do Código Penal, ou a mitigação da exasperação da pena, além do reconhecimento do concurso formal de crimes, da fixação do regime inicial aberto e da detração da pena. (...) – apelante Luís Henrique que igualmente admitiu que guardava em sua residência uma arma e munições calibre .32, a qual pertencia ao corréu Luiz Ricardo. Tese de desclassificação da conduta – Cabimento. Apelante que não portava a arma no momento da abordagem, mas sim a guardava para terceiro em sua residência – ato de guardar arma de fogo e munição em residência que tipifica o art. 12, da Lei nº 10.826/03 – desclassificação que se impõe neste caso concreto.

Crime de associação criminosa - Autoria e materialidade comprovadas - Acusado Luís Henrique e seus comparsas que agiam de maneira organizada, formando, assim, uma associação com o fim de praticar crimes patrimoniais - Roubos a motocicletas - Condenação do réu que se mantém. (...) Preliminar rejeitada. Recurso da Defesa parcialmente provido, com desclassificação para o art. 12, da Lei nº 10.826/03 e consequente readequação da pena. Comunicação à VEC sobre o resultado do julgamento. (TJSP, Apelação Criminal n.º 1502521-60.2020.8.26.0544, 8ª Câmara de Direito Criminal, Relator Ely Amioka, julgado em 10/06/2022)

Nessa conjuntura, tem-se que a conduta narrada na exordial acusatória será analisada na forma do art. 12 da Lei n.º 10.826/03.

Registrada essa ponderação, a matéria de fundo.

Pois bem, a materialidade dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e posse irregular de armamento de fogo de uso permitido está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de f. 25-27, que atesta terem sido apreendidos os entorpecentes e as munições em posse dos acusados.

As substâncias entorpecentes foram submetidas a exame pericial (f. 138-143), sendo que o resultado foi positivo para "cocaína" e "maconha", drogas de uso proscrito no Brasil.

Também as munições de arma de fogo de uso permitido que se encontravam em posse dos denunciados foram submetidas a laudo pericial (f. 231-236, 260-262 e 290-292), que constatou tratarem-se de: um cartucho de munição de arma de fogo, íntegro, recarregado, do calibre nominal 9 x 19 mm (9 mm Parabellum) com potencialidade lesiva (f. 232); três cartuchos calibre nominal 22 com potencialidade lesiva da munição (f. 235); dois estojos de cartucho de munição de arma de fogo vazios, do calibre nominal .38" Special (f. 262); e nove estojos de cartuchos de munição de arma de fogo vazios, do calibre nominal .22" LR (Long Rifle) (f. 291).

No ponto, as munições estavam sob a guarda dos acusados, no interior da residência de um deles (art. 12 da Lei n.º 10.826/03).

A autoria delitiva também é inconteste.

Os policiais civis, ouvidos sob o crivo do contraditório, foram contestes nos pontos essenciais e confirmaram a ocorrência dos fatos descritos na denúncia.

Relatam que estavam investigando uma denúncia de crime de extorsão mediante sequestro e lograram êxito em identificar o local que havia servido como cativado. Diligenciaram ao local para colher informações e, ao chamarem no imóvel, foram atendidos pelo réu Erick Aparecido Xavier, que se identificou como o proprietário. O réu Richard Teófilo Souza estava também dentro do imóvel, atrás do corréu, e perguntaram a ele se ele era vítima de sequestro, em razão do crime que estavam investigando; ele negou e disse que era amigo de Erick Aparecido Xavier.

Conversando com o acusado, da porta, avistaram dentro da casa algumas munições de arma de fogo em cima de uma mesa. Questionaram-no, e ele disse não ter ciência sobre o roubo, tampouco sobre as munições. No mesmo quintal do imóvel, havia um cômodo que estava trancado. Sentiram cheiro de drogas e questionaram o réu sobre esse cômodo; o acusado afirmou que fazia parte do imóvel, pegou as chaves e abriu o cadeado que o trancava. Dentro dele havia drogas e utensílios relacionados à produção de entorpecentes, como balanças, liquidificadores, bacias e anotações de contabilidade do tráfico. O acusado Erick Aparecido Xavier negou ter ciência das drogas, mas disse que os liquidificadores eram seus. Conduziram-nos, então, até a Delegacia de Polícia, e a vítima do roubo reconheceu Erick Aparecido Xavier como sendo um dos agentes daquele crime.

O réu Erick Aparecido Xavier alega em seu interrogatório que, no dia dos fatos, recebeu R\$ 100,00 para vigiar a casa onde foram apreendidas as munições e os entorpecentes. Não tinha envolvimento com o tráfico, e não sabia da existência das drogas no local. Aduz que não autorizou a entrada dos policiais; nega que as munições estivessem visíveis. Não autorizou a abertura do cômodo que estava trancado, sendo que o policial estourou o cadeado para abri-lo.

O acusado Richard Teófilo Souza aduz que foi pago para vigiar a casa, recebeu R\$ 100,00 para tanto e não sabe o que o corréu estava fazendo lá, pois não o conhece. Diz que os policiais chegaram invadindo a casa, revirando tudo e arrombaram o cadeado que trancava o cômodo que ficava no quintal.

Estão isoladas nos autos, contudo, as versões dos acusados de que não tinham ciência das drogas. Chega a ser fantasiosa a versão de que uma pessoa desconhecida pagaria a quantia de R\$ 100,00 para cada um deles, a fim de que eles ficassem numa casa vazia, sem saberem que havia coisas ilícitas no local.

Carece de verossimilhança, outrossim, a alegação de que os acusados não se conheciam, já que estavam no mesmo imóvel pequeno às 07h00min e apresentaram a mesma versão em juízo, de que receberam R\$ 100,00 para vigiar a casa. Ademais, segundo os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório, os réus disseram que eram amigos no momento da abordagem.

Outro ponto inverossímil nos interrogatórios dos réus é a alegação de que os policiais invadiram o imóvel e estouraram o cadeado que trancava o cômodo. Isso porque os policiais afirmam, em depoimento uníssono, que o que despertou a suspeita em relação aos acusados, além da investigação relacionada à extorsão mediante sequestro, foi precisamente o fato de terem visto as munições de arma de fogo em cima da mesa, quando estavam na porta do imóvel.

Esse fato, por si só, serviria de justa causa aos policiais para ingressarem no imóvel e procederem à busca no local, eis que seria caso de flagrante delito (art. 5.º, XI, da CF). Assim, contudo, não agiram. A par disso, ao sentirem cheiro de droga vindo do cômodo que ficava no mesmo quintal, questionaram ao acusado Erick Aparecido Xavier se a edícula pertencia à casa dele (já que ele havia afirmado que era proprietário); diante da resposta positiva, solicitaram que ele abrisse o cadeado que trancava esse cômodo, o que foi de pronto atendido.

Ressalte-se que os dois policiais ouvidos em juízo afirmaram que o réu pegou a chave do cadeado e o abriu. Dentro do cômodo, havia as drogas, liquidificadores, anotações de tráfico e outros objetos relacionados à traficância.

E está cabalmente demonstrada a mentira nas alegações de ambos os réus, que afirmaram que os policiais arrombaram o cadeado que trancava o cômodo.

Confira-se, no ponto, o laudo pericial de f. 225-230, que comprova que o cadeado que trancava o cômodo não foi violado, havendo perícia, inclusive, da chave que o abriu – fornecida e utilizada pelo réu Erick Aparecido Xavier no momento da prisão em flagrante delito.

Desse modo, nada há que se falar em ilegalidade na apreensão das drogas ou das munições de arma de fogo, porquanto os policiais civis agiram com base em justa causa (hipótese de flagrante delito), havendo, no ponto, fundada suspeita de que os acusados estavam praticando tráfico ilícito de entorpecentes – além da posse ilegal de munição de arma de fogo.

Ora, como os policiais avistaram as munições de arma de fogo assim que o acusado abriu a porta, era de se esperar que houvesse, por exemplo, armamento de uso restrito ou proibido armazenado no cômodo que estava trancado.

Ao revés, foram encontradas as substâncias entorpecentes destinadas ao tráfico ilícito – cujo odor, aliás, os policiais já haviam sentido antes da abertura do cadeado.

Não há mácula, pois, nas condutas dos policiais.

A par disso, ambas as testemunhas disseram que o réu Erick Aparecido Xavier, no momento em que o cômodo foi aberto, disse que os liquidificadores que estavam lá eram seus.

E, conforme o laudo pericial de f. 272-284, foram encontrados resquícios de cocaína nos objetos:

Nos objetos supra descritos, foram observados em suas bases e copos, resquícios de material sólido particulado de cor branca amarelada. O referido material foi coletado e submetido aos testes de constatação provisória (teste colorimétrico de Scott) e de constatação definitiva (cromatografia em camada delgada) para a detecção de COCAÍNA.

O teste colorimétrico de Scott consiste na utilização de uma solução de tiocianato de cobalto em meio ácido. O tiocianato de cobalto na presença de COCAÍNA produz um complexo de coloração azulada. O resultado obtido foi POSITIVO para a referida substância.

(f. 282)

Aliás, em juízo, os réus afirmam não conhecer os policiais civis que realizaram a

abordagem, não sabendo indicar por que razão eles os acusariam falsamente. E nada há nos autos que indique eventual intenção espúria dos policiais civis de incriminar injustamente os acusados. Assim, seus depoimentos merecem credibilidade e são valiosos para a condenação. Entendimento contrário acarretaria a ruína do sistema de segurança pública do Estado.

Frise-se, nesse passo, que as circunstâncias da abordagem, noticiadas nos depoimentos dos policiais, permitem presumir que as drogas apreendidas com os acusados se destinavam ao tráfico, não havendo espaço para eventual desclassificação da conduta praticada.

No mesmo sentido, as munições de arma de fogo foram encontradas em posse dos acusados, dentro do imóvel onde os dois estavam e cuja propriedade o réu Erick Aparecido Xavier reclamou.

As munições foram periciadas, como ressaltado acima, estando aptas a disparo.

E todas as munições apreendidas destinam-se a armas de fogo de uso permitido, de acordo com o Anexo A da Portaria n.º 1.222/2019 emitida pelo Ministério da Defesa – 9 mm Parabellum (f. 232), 22” LR (Long Rifle) (f. 235), 38” Special (f. 262), e 22” LR (Long Rifle) (f. 291).

Assim, está comprovada a prática do delito tipificado no art. 12 da Lei n.º 10.826/03.

Frise-se, por oportuno, ser descabida a tese defensiva de que os réus incorreram em erro de tipo, por não saberem que havia munições de arma de fogo no local. Como já pontuado, os policiais civis foram firmes em seus depoimentos ao dizerem que as munições estavam em cima da mesa, a plena vista de todos que estavam no local. Ainda sobre a imputação do delito previsto na Lei n.º 10.826/03, a defesa sustenta que não se trataria de crime autônomo, mas, sim, de causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei n.º 11.343/06:

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

(...)

IV - o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva;

A tese, com a devida vênia, é desprovida de fundamento fático.

Ao revés do que alega a defesa, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes não foi praticado com “emprego de arma de fogo” como “processo de intimidação difusa ou coletiva”. Aliás, sequer havia arma de fogo em posse dos acusados – apenas munições.

O crime do art. 12 Lei n.º 10.826/03 foi praticado de forma autônoma pelos acusados, que tinham a posse de munições de armas de fogo de uso permitido e, no mesmo local, também tinham a posse de substâncias entorpecentes. Não havia, porém, ligação entre as munições e as drogas encontradas.

Vai rejeitada, nesses termos, a tese defensiva.

No que tange ao delito de associação, também procede a pretensão punitiva estatal, tal como bem ponderado pela Promotora de Justiça em suas alegações finais.

Deveras, o tipo penal previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/06 demanda, para a sua configuração, além da associação de duas ou mais pessoas, prova da estabilidade e permanência da associação criminosa.

A esse respeito, os réus foram encontrados em conjunto, no mesmo imóvel onde estavam armazenadas as drogas, com diversos petrechos para a preparação e acondicionamento dos entorpecentes, tais como balança de precisão, baldes e liquidificadores – todos com resquícios de drogas.

Ora, como já ressaltado, não é crível que eles não se conhecessem e não estivessem praticando os delitos juntos.

Ao contrário, os réus traficavam juntos, tinham lugar reservado para armazenamento das drogas, onde eles guardavam, inclusive, os petrechos relacionados à traficância.

Está suficientemente demonstrada, portanto, a estabilidade e a permanência da associação entre os dois para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

As provas, portanto, são bastantes para a condenação.

No que tange à aplicação da causa de diminuição de pena à reprimenda do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, atento aos recentes julgados dos tribunais superiores sobre o assunto, revejo posicionamento anterior e passo a não vislumbrar inconstitucionalidade na incidência deste privilégio.

Explica-se.

A Terceira Seção do C. STJ, embora não tenha se pronunciado diretamente sobre a inconstitucionalidade ou não da causa especial de diminuição de pena em tela, ao revisar o REsp n.º 1.329.088/RS, afetado para julgamento pelo rito dos recursos repetitivos (arts. 1.036 e seguintes do CPC), no Tema n.º 600, firmou a seguinte tese: "O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo".

Com a revisão da tese anterior, o tribunal superior cancelou seu enunciado de súmula n.º 512, que assim dispunha: "A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas".

Foram, outrossim, compiladas as seguintes teses sobre o tema, na edição n.º 131 da Jurisprudência em Teses do C. STJ:

21) O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo. (Tese revisada sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015 - TEMA 600)

22) A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas só pode ser aplicada se todos os requisitos, cumulativamente, estiverem presentes.

23) É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando há condenação simultânea do agente nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa.

25) Diante da ausência de parâmetros legais, é possível que a fração de redução da causa de diminuição de pena estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 seja modulada em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito.

45) A natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas simultaneamente para justificar o aumento da pena-base e para afastar a redução prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob pena de caracterizar bis in idem.

46) A utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, não configura bis in idem, tratando-se de hipótese diversa da Repercussão Geral - TEMA 712/STF.

48) A utilização da reincidência como agravante genérica é circunstância que afasta a causa especial de diminuição da pena do crime de tráfico, e não caracteriza bis in idem.

Em todos esses enunciados, bem como no Tema Repetitivo n.º 600, o C. STJ admitiu indiretamente a viabilidade de incidência da circunstância privilegiadora do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, desde que observados cumulativamente os requisitos do dispositivo.

Também o STF firmou tese admitindo a aplicação do privilégio ao delito de tráfico, no julgamento do Tema n.º 712 de Repercussão Geral, no qual se firmou a seguinte tese: "As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena".

Desse modo, nada há que se falar sobre eventual inconstitucionalidade da norma disposta no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006.

No caso concreto, todavia, é incabível a aplicação da forma privilegiada do tráfico.

Com efeito, os réus estão sendo condenados pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes e, conjuntamente, pelo delito de associação para o tráfico. É incompatível com essa condenação, portanto, a incidência do privilégio, nos termos do enunciado 23 da edição n.º 131 da Jurisprudência em Teses do C. STJ, que assim aduz, in verbis: "É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena

prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando há condenação simultânea do agente nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa”.

Inviável, nesses termos, a incidência da circunstância privilegiadora.

Nessa conjuntura, verifica-se que há subsunção das condutas dos acusados aos tipos penais previstos nos arts. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/06, e art. 12 da Lei n.º 10.826/03, todos na forma do artigo 69, caput, do CP, uma vez que, previamente ajustados e com unidade de desígnios, com vontade e consciência, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e guardavam e tinham em depósito as porções de drogas indicadas na denúncia, sem autorização legal ou regulamentar. Ainda, com vontade e consciência, os réus possuíam e mantinham sob sua guarda munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de residência. Os fatos são ilícitos, pois reprovados pela lei penal, sendo que não foram alegadas ou comprovadas quaisquer causas justificantes.

Os denunciados eram maiores de 18 anos de idade (imputáveis), tinham potencial consciência da ilicitude e, nas circunstâncias, era-lhes exigida conduta diversa. Presente, portanto, a culpabilidade.

Assim, passo a aplicar a pena, seguindo o método trifásico previsto no art. 68 do CP.

Inicialmente destaco que este Juízo, para a estipulação da pena base e o cálculo do aumento decorrente de eventual circunstância judicial – inclusive para a aferição de pena de multa cominada isolada ou cumulativamente –, leva em consideração o resultado do intervalo, abstratamente previsto pela lei, entre a pena mínima e a pena máxima, seguido da divisão por oito, conforme ensina Ricardo Augusto Schmitt: “O critério que vem sendo utilizado pelos Tribunais Superiores repousa numa situação prática e simples, que tem resultado a partir da obtenção do intervalo da pena prevista em abstrato ao tipo (máximo – mínimo), devendo, em seguida, ser encontrada sua oitava parte (1/8), ou seja, dividir o resultado obtido por 8 (oito), em vista de ser este o número de circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Com esse raciocínio, chegamos ao patamar exato de valoração de cada uma das circunstâncias judiciais (com absoluta proporcionalidade), o qual servirá de parâmetro para o julgador promover suas análises individuais” (Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Podivm. 6ª edição. Salvador/Bahia. 2011. p. 115/116).

A par disso, para a hipótese específica destes autos, incide o disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, que assim dispõe, in verbis: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Neste cenário normativo, verifica-se que dois vetores do art. 42 da Lei de Drogas já estão inseridos expressamente nos parâmetros do art. 59 do CP – “personalidade e conduta social do agente”. Outrossim, tem-se que “a natureza e a quantidade da substância ou produto” podem ser analisadas no contexto das “circunstâncias” do delito, outro vetor do art. 59 do CP.

Assim, e pela necessidade da “preponderância” prevista no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, alvitra-se valorar a personalidade e a conduta social do agente, assim como as circunstâncias do delito, com um peso mais significativo.

Como ressaltado anteriormente, costuma-se considerar o intervalo, abstratamente previsto pela lei, entre a pena mínima e a pena máxima, seguido da divisão por oito. Todavia, para preponderância aqui perseguida, prudente que a divisão seja feita por 11, uma vez que as circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas podem ser enquadradas em três vetores, tal como delineado acima – personalidade, conduta social e circunstâncias.

Fazendo isso, porém, deve-se dar aos vetores preponderantes o peso de 2/11, e aos demais, o de 1/11.

Assim, nos termos dos arts. 59 do CP e 42 da Lei n.º 11.343/06, à culpabilidade, aos antecedentes, aos motivos e às consequências do crime, bem como ao

comportamento da vítima (irrelevante em se tratando de crime vago como o tráfico de drogas), deve-se atribuir o peso de 1/11, constituindo 5/11 da pena-base; à conduta social e à personalidade do agente, assim como às circunstâncias, deve-se aplicar o peso de 2/11, configurando 6/11 da pena-base.

Desse modo, estará garantida a aplicação preponderante do art. 42 da Lei de Drogas, bem como assegurada, de forma mais escorreita e técnica, a individualização da pena.

Todavia, é necessário ressaltar que a fração indicada não deve ser aplicada de forma precisa, matematicamente. Trata-se, na verdade, de mero parâmetro para a fixação da reprimenda penal, de modo que as circunstâncias do caso concreto podem ensejar a exasperação maior ou menor da pena – ou maior ou menor compensação em caso de vetores favoráveis.

Feitas essas observações, à dosimetria da pena.

Pois bem, os acusados são primários e não ostentam maus antecedentes (f. 216-217). Por outro lado, as circunstâncias dos delitos de tráfico e de associação são desfavoráveis. Com efeito, os denunciados estavam na posse de significativa quantidade de entorpecentes – 188,73g de cocaína (f. 139), droga de alto poder destrutivo.

Além disso, importante ressaltar que o réu Erick Aparecido Xavier, em seu interrogatório, afirmou ser usuário de drogas e consumi-las com frequência. Tal circunstância é desfavorável à conduta social do denunciado, já que, além de traficar drogas, financia indiretamente esse delito equiparado a hediondo, crime esse que vem, cada vez mais, corroendo famílias e a própria sociedade.

As demais circunstâncias do art. 59 do CP não são desfavoráveis aos réus, ou são normais aos tipos penais.

Nesse contexto, havendo duas circunstâncias judiciais negativas preponderantes para os crimes de associação e de tráfico (circunstâncias do crime e conduta social) e uma circunstância judicial negativa para o delito de posse de armamento de uso permitido, fixo as penas bases do réu Erick Aparecido Xavier em: a) 05 anos e 04 meses de reclusão – e 866 dias-multa para o crime de associação para o tráfico; b) 08 anos e 04 meses de reclusão – e 833 dias-multa para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes; e c) 01 ano, 01 mês e 15 dias de detenção – e 53 dias-multa para o crime do art. 12 da Lei n.º 10.826/03.

Quanto ao réu Richard Teofilo Souza, havendo uma circunstância judicial preponderante negativa para os crimes de associação e de tráfico (circunstâncias do crime), fixo as penas bases em: a) 04 anos e 02 meses de reclusão – e 783 dias-multa para o crime de associação para o tráfico; b) 06 anos e 08 meses de reclusão – e 666 dias-multa para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes; e c) 01 ano de detenção – e 10 dias-multa para o crime do art. 12 da Lei n.º 10.826/03.

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes em relação ao réu Erick Aparecido Xavier, razão pela qual mantenho as penas acima estipuladas, provisoriamente.

Por outro lado, na segunda fase, há a atenuante da menoridade relativa para ser considerada em relação ao réu Richard Teofilo Souza, nos termos do art. 65, I, do CP, tendo em vista que acusado era menor de 21 anos de idade na data dos fatos (f. 10).

Contudo, tendo em vista o enunciado da súmula n.º 231 do STJ, do qual se comunga entendimento, mantenho a pena do delito do art. 12 da Lei n.º 10.826/03 tal como acima estipulada, provisoriamente.

Noutra senda, reduzo as penas dos demais crimes em 1/6, fixando-as, provisoriamente, em: a) 03 anos, 05 meses e 20 dias de reclusão – e 700 dias-multa (considerando a aplicação da súmula n.º 231 do STJ) para o crime de associação para o tráfico; b) 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão – e 555 dias-multa para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Por fim, na última fase, não havendo causas de diminuição ou de aumento a serem consideradas, fixo as reprimendas, agora definitivamente:

(i) do réu Erick Aparecido Xavier em: a) 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão – e 866 (oitocentos e sessenta e seis) dias-multa para o crime de associação para o tráfico; b) 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão – e

833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes; e c) 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção - e 53 (cinquenta e três) dias-multa para o crime do art. 12 da Lei n.º 10.826/03. (ii) do réu Richard Teófilo Souza em: a) 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 20 dias de reclusão - e 700 (setecentos) dias-multa para o crime de associação para o tráfico; b) 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão - e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes; e c) 01 (um) ano de detenção - e 10 (dez) dias-multa para o crime do art. 12 da Lei n.º 10.826/03.

Aplicando-se o art. 69 do CP, ficam as penas assim estipuladas:

(i) do réu Erick Aparecido Xavier em: 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão; 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção; e 1.752 (mil, setecentos e cinquenta e dois) dias-multa; e (ii) do réu Richard Teófilo Souza em: 09 (nove) anos e 10 (dez) dias de reclusão; 01 (um) ano de detenção; e 1.265 (mil, duzentos e sessenta e cinco) dias-multa. O valor do dia-multa fica estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no país na data dos fatos, considerada a presumida precariedade da situação financeira dos denunciados, valor a ser atualizado quando do efetivo pagamento. De acordo com o art. 2.º, § 1.º, da Lei n.º 8.072/90, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento das penas privativas de liberdade.

Ressalte-se, nesse passo, que é inconstitucional a Lei n.º 12.736/2012, que determina a consideração da detração penal para fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Isso porque viola o princípio constitucional da isonomia, já que, aplicando-se a referida lei, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais. Assim, o sentenciado condenado à pena privativa de liberdade, e que tenha sido preso provisoriamente, terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovido de regime sem a observância do seu comportamento carcerário (requisito subjetivo). Por outro lado, o condenado que não tenha cumprido prisão provisória deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais, a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5.º, caput).

Dessa forma, deixo de aplicar a Lei n.º 12.736/2012.

A detração deverá ser observada pelo juízo da execução, não havendo qualquer prejuízo aos acusados.

Mantenho a custódia cautelar dos denunciados, pois não modificadas as situações que determinaram a sua necessidade. Recomendo os réus na prisão onde se encontram.

Incabível a substituição ou a suspensão condicional da pena privativa de liberdade (CP, arts. 44, inciso I, e 77, caput).

Em razão do exposto:

(a) julgo extinta sem resolução do mérito a pretensão acusatória em relação ao crime previsto no art. 16 da Lei n.º 10.826/03; e

(b) na parte conhecida, julgo parcialmente procedente a pretensão acusatória para os seguintes efeitos:

(b.1) condenar o réu ERICK APARECIDO XAVIER, já qualificado, ao cumprimento das penas de 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão; 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção - e ao pagamento de 1.752 (mil, setecentos e cinquenta e dois) dias-multa, pela infração aos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/06, e art. 12 da Lei n.º 10.826/03, a ser cumprida em regime inicial fechado; e

(b.2) condenar o réu RICHARD TEOFILO SOUZA, já qualificado, ao cumprimento da pena de 09 (nove) anos e 10 (dez) dias de reclusão; 01 (um) ano de detenção - e ao pagamento de 1.265 (mil, duzentos e sessenta e cinco) dias-multa, pela infração aos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/06, e art. 12 da Lei n.º 10.826/03, a ser cumprida em regime inicial fechado.

O valor do dia-multa fica estabelecido, para ambos os réus, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo federal vigente no país na data dos fatos, valor a ser atualizado quando do efetivo pagamento.

Expeçam-se as guias de execução provisória.

Deixo de fixar a verba mínima indenizatória do art. 387, IV, do CPP, pois se trata de crime vago.

Determino a perda dos bens apreendidos a favor da União, nos termos dos arts. 91, II, do CP e 63, I, da Lei n.º 11.343/2006.

Custas pelos réus (CPP, art. 804), no valor de 100 UFESPs (Lei n.º 11.608/2003, art. 4.º, § 9.º, "a"), cuja exigibilidade fica suspensa em razão de estarem litigando sob o pálio da assistência judiciária gratuita, que agora lhes fica deferida, anotando-se.

Após o trânsito em julgado:

- (a) lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados ou instituto equivalente;
- (b) expeçam-se as guias de execução definitivas;
- (c) oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, comunicando a condenação dos réus, com suas devidas identificações, acompanhadas do inteiro teor da presente sentença, para cumprimento do quanto disposto pelo art. 71, § 2º, do Código Eleitoral combinado com o art. 15, inciso III, da Constituição Federal;
- (d) oficie-se ao Senad, nos termos do art. 63, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006; e
- (e) arquivem-se os autos com as anotações e comunicações necessárias.

P.I.C.

Itapevi, 11 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA